

1503659-21.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503659-21.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503659-21.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2323259/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21646741 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2984/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2323259 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2984/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2323259/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adryel Gonçalves de Oliveira e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ADRYEL GONÇALVES DE OLIVERA e WESLEY ALEXANDRE CARDOSO VICENTE FERREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, em 28 de novembro de 2021, por volta das 19h30min, na Rua João Maesi, 440, Jardim Residencial Antônio Simonetti, nesta cidade e comarca de Limeira, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, um total de 150 (cento e cinquenta) porções de maconha, com peso aproximado de 620g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, os réus traziam consigo, guardavam e tinham em depósito as porções de maconha mencionadas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram os denunciados próximo ao veículo Fiat/Palio, oportunidade em que viram ADRYEL entregar algo ao motorista do respectivo veículo.

Diante disso, os milicianos resolveram abordá-los, sendo que, ao perceberem a presença da viatura, os acusados tentaram se evadir do local e WESLEY dispensou um saquinho ao solo, ocasião em que foram detidos.

Em busca pessoal, os policiais localizaram em poder de WESLEY 05 (cinco) porções de maconha e a quantia de R\$10,00 (dez) reais, sendo que, no interior do saquinho dispensado foram encontradas mais 03 (três) porções de maconha, além da quantia de R\$22,15 (vinte e dois reais e quinze centavos).

Indagados, os acusados admitiram aos policiais, informalmente, o tráfico de drogas no local.

Em seguida, no local indicado pelo réu ADRYEL, os milicianos localizaram no muro de uma casa em construção mais 05 (cinco) porções de maconha e, próximo ao local da abordagem, os agentes públicos apreenderam no interior de uma lixeira, acondicionadas em um saco plástico, 137 (cento e trinta e sete) porções de maconha, totalizando 150 (cento e cinquenta) unidades, todas embaladas individualmente e semelhantes entre si, que seriam comercializadas por eles.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 117).

A denúncia foi recebida em 8 de fevereiro de 2022 (fls. 125/126).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e os réus, interrogados ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defesa ofereceram alegações finais em audiência.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, aprecio as preliminares levantadas pela Defesa.

De início, saliento que as partes (Ministério Público e Defensoria Pública) iniciaram a formulação de perguntas diretamente às testemunhas, bastando verificar o teor da mídia de audiência.

Houve obediência ao disposto no artigo 212 do CPP, que adotou o cross-examination no nosso ordenamento jurídico, não havendo adoção do sistema presidencialista por este magistrado.

Não há que se falar em prova ilícita em razão da não realização do "Aviso de Miranda" quando da prisão em flagrante. Ora, não há, no direito brasileiro, qualquer regra explícita sobre o chamado "Aviso de Miranda" (advertência de Miranda ou "Miranda rights"), originado do direito norte-americano, do julgamento Miranda versus Arizona, da Suprema Corte Americana (384 U.S 436, de 1966).

O artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal dispõe que "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado". Ademais, não serão consideradas lícitas as provas obtidas a partir de declarações de quem for preso sem a prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio (CPP, artigo 157).

Entretanto, para fins de caracterização da violação do direito ao silêncio e a não autoincriminação, é necessário a existência de interrogatório "forçado", em que o custodiado é obrigado a falar, com a existência de um ambiente de intimidação, o que diminuiu o direito a não se incriminar.

No caso em tela, não foi isso o que se verificou. Para o reconhecimento da nulidade por conta da falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio, há a necessidade da demonstração de prejuízo concreto, o que não é o caso em discussão, já que a conduta ilícita dos réus pode ser extraída de outros elementos de prova, como a oral, pericial e documental.

Tal conclusão não destoa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada (...)" (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). A preliminar de prova ilícita em razão da ilegalidade da busca pessoal será analisada em conjunto com o mérito da ação penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (07/09) auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo pericial com resultado positivo para "maconha" (fls. 45/47 e 77/79), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, o acusado ADRYEL permaneceu calado (fls. 16).

Em Juízo, o réu ADRYEL disse que tem 18 anos. Trabalha no supermercado como empacotador. Estava no ponto de tráfico. Iria comprar drogas. Seu tio estava no veículo. Nada passou para o condutor. Correu ao ver a viatura. Havia cinco buchas em seu poder e as dispensou quando viu os guardas. Havia comprado apenas essa droga. Tinha dinheiro em seu poder, era seu dia de folga. Os fatos ocorreram no domingo. Não costumava frequentar aquele ponto de drogas. Conhece Wesley de vista.

O local da prisão é perto da sua casa. Não se recorda de encontro de drogas no muro e na lixeira. O pessoal correu ao ver a viatura. Seu tio avisou que os policiais estavam na rua de cima. Seu tio havia voltado da casa do seu pai. Não sabe a razão do seu parente ter fugido. Não sabe qual a marca e modelo do automóvel dele. Seu tio se chama Evandro. Só foi comprar drogas, não costuma frequentar ali. Seus pais não gostam que ele fuma maconha. Havia sido preso em flagrante um mês antes por tráfico de drogas, mas o menino assumiu tudo, não tem qualquer responsabilidade com aquele episódio. Gasta cinquenta reais por mês com maconha (mídia).

Perante a Autoridade Policial, o réu WESLEY negou a acusação, esclarecendo que eram dele somente as três porções de maconha que foram apreendidas em seu poder. Negou que estava no local para vender drogas (fls. 17).

Em Juízo, o acusado WESLEY disse que tem 19 anos. Trabalha como ajudante. Havia acabado de sair do sítio. Sua mãe deu dinheiro para comprar buchas de maconha. Foi lá no ponto, na biqueira. Encontrou Adriel, só o conhece de vista. Queria cinco porções por vinte e dois reais. Pegou as barangas. Os policiais desceram e o abordaram. Ficou assustado com a polícia. Jogou as barangas no chão. Não conhecia os guardas. Não costumava frequentar esse local. Mora no sítio, é longe dali. Adryel correu dos guardas. Não fugiu da polícia (mídia)

A versão deles não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses dos réus.

O policial militar Ivan Dias de Jesus disse que faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram um veículo Fiat Palio estacionado. O local é conhecido pela traficância. Havia duas pessoas em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, viu que o acusado Adryel passava algo para o condutor do veículo, típico ato de comércio de drogas. O automóvel Palio saiu em alta velocidade ao ver a presença deles. Adryel saiu correndo na mesma direção do Palio. Desembarcaram da viatura. Houve a abordagem de Wesley. Houve dispensa de um pacote de bolacha por parte deste réu, contendo dinheiro e três porções de maconha. Wesley tinha um aparelho celular em seu poder. O motorista da viatura fez a detenção do réu que fugiu. Com Adryel havia cinco porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Indagados, ambos confessaram a prática do tráfico de drogas. Foi Adryel quem indicou onde estavam as demais porções de maconha encontradas no muro. Defronte ao local da abordagem havia uma construção onde realmente tinha um muro com lajotas. Nos furos das lajotas houve o encontro de mais cinco porções de maconha. Fizeram varredura do local da prisão como é de costume. Conforme o cabo foi fazendo a varredura, perto de uma lixeira, perceberam que os réus ficaram muito nervosos. Foi nesse momento que seu colega de farda localizou um saco plástico contendo mais cento e pouca porções de maconha. Todas as drogas apreendidas eram idênticas. Não conhecia os abordados até então. No local que Adryel indicou foram encontradas cinco porções de maconha. O local da varredura não foi indicado pelos réus, muito menos o local da lixeira onde foi localizada a maior parte das drogas (mídia).

O policial militar Edirlei Aparecido Narcizo contou que os fatos ocorreram no domingo. Faziam patrulhamento pelo bairro. Quando entraram na via citada, viram o veículo Fiat Palio e duas pessoas perto daquele motorista, em atitude suspeita. O acusado Adryel fazia transação típica de tráfico de drogas. O local já é muito conhecido pela traficância. Com a aproximação da polícia o veículo Fiat fugiu em alta velocidade. Adryel, por sua vez, saiu correndo na direção daquele carro e foi detido logo em seguida. Wesley dispensou um pacote de bolacha contendo dinheiro e drogas. Wesley tinha um telefone celular. Adryel foi detido e viu que foram encontrados em poder dele cinco porções de maconha e dinheiro. Indagados, ambos confirmaram a prática do tráfico. Adryel indicou que no muro da construção havia mais porções de maconha. No local indicado encontraram cinco porções. Fazendo varredura que é de praxe, viram que os réus ficaram muito nervosos. Na lixeira

foram localizadas mais de cento e trinta e sete porções de maconha. Todas as drogas eram idênticas. Deram voz de prisão a ambos os acusados (mídia).

De extrema valia o depoimento de policiais militares, mormente se não há indícios de que queiram prejudicar injustamente os réus.

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram os acusados ADRYEL e WESLEY perto de um automóvel Fiat Palio, em local conhecido pelo tráfico de drogas.

Os guardas viram ADRYEL entregando algo para o motorista, em atitude típica de tráfico. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor do veículo deixou o local em alta velocidade, enquanto ADRYEL correu na mesma direção do automóvel e WESLEY ficou no local.

Os policiais viram que WESLEY dispensou no chão um saquinho de bolacha contendo três porções de maconha e dinheiro. Com ADRYEL, foram apreendidas cinco porções de maconha e dinheiro.

No muro de uma casa em construção, em local indicado por ADRYEL, outras cinco porções de maconha foram localizadas. Perto de onde os réus estavam, dentro de uma lixeira, acondicionadas em saco plástico, os agentes públicos apreenderam mais 137 porções de maconha, totalizando 150 unidades, todas as drogas idênticas.

Indagados, eles confessaram a prática do tráfico.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas a droga (maconha), as circunstâncias da prisão em flagrante, o encontro de quantia em dinheiro sem justificativa, o local da prisão e o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar os réus como sendo pessoas envolvidas no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São

Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Observo que não foram arroladas testemunhas de defesa que pudessem corroborar a versão dos acusados de não terem qualquer envolvimento com o delito de tráfico de drogas, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que faziam o patrulhamento preventivo e os prenderam em flagrante delito.

É inquestionável que a ação da polícia militar se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Durante o patrulhamento ostensivo e preventivo, os acusados foram abordados em local conhecido pela traficância ilícita, em atitude típica de comércio de drogas em relação ao condutor de um veículo automotor, com fuga pelo motorista e por um dos réus, que resultou no encontro de 150 (cento e cinquenta) porções de maconha

pesando 620 gramas e quantia em dinheiro, circunstâncias estas que somadas geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizaram a busca em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. (...)
1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (...)" 6. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).

E não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, e natureza das drogas apreendidas, das circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador dos policiais militares.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)"(TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que os acusados não tinham trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra os réus, não existindo justificativas para seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

ADRYEL GONÇALVES DE OLIVERA

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014),

fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem.

Não é caso de reconhecimento de agravantes e atenuantes. A pena já foi fixada no mínimo legal, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser aplicada. Com efeito, observo que o réu denota dedicação à atividade criminosa em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida em seu poder, com o encontro de 150 (cento e cinquenta) porções de maconha, com peso aproximado de 620 gramas, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei em tais circunstâncias.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente que adoto como razão de decidir:

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (...) 5. Dosimetria da pena 6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). 7. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas deve ser o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, bem como em razão das particularidades do caso concreto. Precedente do STF. Além da quantidade da pena imposta. 9. Provimento do recurso Ministerial, com expedição de mandado de prisão”. (TJSP; Apelação 0004783-35.2014.8.26.0296; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é na mesma direção:

“(...) III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento

da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos (865,8 g de maconha e 3,4 g de cocaína), e nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, em decorrência de denúncia de sua genitora de que aquele guardava um tablete de maconha em sua residência) e a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas e a outra parte encontrada em sua residência, juntamente com tesoura e faca com resquício de cocaína e dinheiro em notas miúdas), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 568.062/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

"(...) 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp n. 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; HC n. 385.437/SP, de minha relatoria, DJe 27/3/2017; HC n. 324.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 8/3/2016. 3. Com relação ao pleito de aplicação da redutora para incidir a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 4. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de 20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, acondicionada em 19 "tijolos", e 254, 850 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo que se falar em bis in idem (e-STJ fl. 492/493). Assim, fica evidenciada fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 5. Por sua vez, em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016. In casu, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

"3. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem

reconhecidamente primários, possuem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Hipótese em que as instâncias antecedentes mantiveram afastada a minorante, por entender que a entrega de gigantesca quantidade de drogas pelo paciente - 29 tijolos de cocaína (28,159 kg) -, não deixa dúvida do seu envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes. Assim, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (...) 6. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza das drogas apreendidas), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. O tema relativo à concessão de regime domiciliar por motivo de doença respiratória não foi debatido na Corte de origem, o que impede a sua análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de origem, observa-se que, em 2/2/2021, certificou-se o trânsito em julgado da condenação. 8. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 552.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade da droga em discussão (cento e cinquenta porções de maconha, com peso aproximado de 620 gramas), sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

WESLEY ALEXANDRE CARDOSO VICENTE FERREIRA

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem.

Não é caso de reconhecimento de agravantes e atenuantes. A pena já foi fixada no mínimo legal, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser aplicada. Com efeito, observo que o réu denota dedicação à atividade criminosas em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida em seu poder, com o encontro de 150 (cento e cinquenta) porções de maconha, com peso

aproximado de 620 gramas, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei em tais circunstâncias.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente que adoto como razão de decidir:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (...) 5. Dosimetria da pena 6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). 7. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas deve ser o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, bem como em razão das particularidades do caso concreto. Precedente do STF. Além da quantidade da pena imposta. 9. Provimento do recurso Ministerial, com expedição de mandado de prisão". (TJSP; Apelação 0004783-35.2014.8.26.0296; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é na mesma direção:

"(...) III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas e diversidade de entorpecentes apreendidos (865,8 g de maconha e 3,4 g de cocaína), e nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, em decorrência de denúncia de sua genitora de que aquele guardava um tablete de maconha em sua residência) e a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas e a outra parte encontrada em sua residência, juntamente com tesoura e faca com resquício de cocaína e dinheiro em notas miúdas), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 568.062/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).

"(...) 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp n. 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; HC n. 385.437/SP, de minha relatoria, DJe 27/3/2017; HC n. 324.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 8/3/2016. 3. Com relação ao pleito de aplicação da redutora para incidir a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 4. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de 20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, acondicionada em 19 "tijolos", e 254, 850 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo que se falar em bis in idem (e-STJ fl. 492/493). Assim, fica evidenciada fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 5. Por sua vez, em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016. In casu, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

"3. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Hipótese em que as instâncias antecedentes mantiveram afastada a minorante, por entender que a entrega de gigantesca quantidade de drogas pelo paciente - 29 tijolos de cocaína (28,159 kg) -, não deixa dúvida do seu envolvimento habitual com o tráfico de entorpecentes. Assim, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (...) 6. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade e natureza das drogas apreendidas), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. O tema relativo à concessão de regime domiciliar por motivo de doença respiratória não foi debatido na Corte de origem, o que impede a sua análise diretamente por

este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de origem, observa-se que, em 2/2/2021, certificou-se o trânsito em julgado da condenação. 8. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 552.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela natureza e quantidade da droga em discussão (cento e cinquenta porções de maconha, com peso aproximado de 620 gramas), sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ADRYEL GONÇALVES DE OLIVERA e WESLEY ALEXANDRE CARDOSO VICENTE FERREIRA, qualificados nos autos, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Os réus não poderão apelar em liberdade, uma vez que permaneceram presos durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de, soltos, voltarem a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser